

1500817-87.2022.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Comarca: Buri

Foro: Foro de Buri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... ponto, sobreleva mencionar que o delito de tráfico de drogas está descrito em tipo penal misto alternativo, de modo que, à caracterização do crime, basta a prática de apenas uma das ações típicas. O efeito prático disso é que, para que se configure o tráfico, não é imprescindível que o réu seja flagrado vendendo a mercadoria proibida, bastando a concretização de qualquer uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buri Foro de Buri Vara Única

Rua Carlos Alberto Pereira Jr, 549, ., Vila Sene - CEP 18290-000, Fone: (15) 3546-2446, Buri-SP - E-mail: buri@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500817-87.2022.8.26.0270

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADOLFO HENRIQUE MARTINEZ e outro

Data da Audiência:

30/08/2022

Aos 30 de agosto de 2022, às 14 horas, em sala de audiências da Vara Única do Foro de Buri, Comarca de Buri, Estado de São Paulo, onde presente se achava na plataforma M. Teams a Excelentíssima Senhora GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Audiência realizada na forma do Provimento CSM nº 2654/2020, Comunicado Conjunto nº 581/2020, Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, §2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Presentes o(a) Promotor(a) de Justiça Dr(a). Augusto Sérgio Costa Vianna, o réu ADOLFO HENRIQUE MARTINEZ, acompanhado(a) de seu(ua) advogada(a) João Ricardo Conharic Sene, o réu Kauã de Lima Lopes, acompanhado de seu advogado Dr. Fernando Manoel Spaluto, e as testemunhas de acusação Clóvis Pereira da Cruz e Alex Azevedo da Silva.

Foi oportunizado aos réus conversa privada com seus defensores, permanecendo no modo "lobby" o(a) MM. Juiz(a), o(a) Promotor(a) e demais participantes.

Iniciados os trabalhos, foi tomado o depoimento da testemunha Clóvis.

Pelo Promotor de Justiça e pelos advogados foi dito que desistia da oitiva da testemunha Alex, o que foi homologado pela MM. Juíza.

Após, o réu Adolfo foi interrogado, nos termos do artigo 185 do CPP, na ausência do réu Kauã.

Depois, procedeu-se ao interrogatório do acusado Kauã.

Ato contínuo, não havendo diligências a serem realizadas, nem outras provas a serem produzidas, pela MM. Juíza foi encerrada a instrução processual.

O representante do Ministério Público manifestou-se oralmente em alegações finais pelo sistema audiovisual. Sucessivamente, a palavra foi dada aos defensores dos

réus, que se manifestaram oralmente em alegações finais.

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA:

"Vistos.

I - RELATÓRIO

ADOLFO HENRIQUE MARTINEZ e KAUÃ DE LIMA LOPES foram denunciados e estão sendo processados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29, do Código Penal.

Isto porque, segundo a denúncia:

"No dia 20 de abril de 2022, por volta das 23h, na Rua Ciro de Albuquerque, n.º 310, Vila Mariazinha, nesta cidade e comarca, ADOLFO HENRIQUE MARTINEZ e KAUÃ DE LIMA LOPES, qualificados e interrogados respectivamente a fls. 04/05 e 07/08, em concurso, traziam consigo drogas, consistentes em (I) 16 (dezesseis) porções de maconha, pesando 19,1g de massa líquida; (II) 88 (oitenta e oito) porções de crack, pesando 16,8 de massa líquida; e (III) 81 (oitenta e uma) porções de cocaína, pesando 13,1 de massa líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 15/16 e laudos de exame químico-toxicológico a fls. 18/29).

Segundo o apurado, chegou ao conhecimento da Polícia Militar que havia cinco pessoas promovendo o tráfico em um campo de futebol.

Uma guarnição compareceu ao local e, de fato, viu cinco pessoas juntas, as quais fugiram ao notarem sua chegada; entretanto, os policiais alcançaram e detiveram KAUÃ, que trazia consigo 16 (dezesseis) porções de maconha, e também ADOLFO, que carregava 88 (oitenta e oito) pedras de crack e 81 (oitenta e um) pinos de cocaína, além de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em dinheiro.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas encontradas, a apreensão de dinheiro, as informações pretéritas e reação dos denunciados à abordagem policial demonstram que os entorpecentes se destinavam à venda."

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022. (fls. 149/150).

O acusado ADOLFO foi citado (fls. 123) e apresentou defesa prévia (fls. 146/147).

O acusado KAUÃ foi citado (fls. 125) e apresentou defesa prévia (fls. 130/132).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas 02 testemunhas arroladas pelo Ministério Público e as mesmas testemunhas arroladas por ambas as Defesas. Ao final, os réus foram interrogados.

Em sede de alegações finais por memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado ao acusado KAUÃ.

Folha de Antecedentes ADOLFO (fls. 194/196) e Certidão do Cartório distribuidor criminal (fls. 192/193).

Folha de Antecedentes KAUÃ (fls. 197/198) e Certidão do Cartório distribuidor criminal (fls. 190/191).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

Finalizada a instrução penal, verifica-se que a prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de apreensão (fls. 15/16), laudos de constatação dos entorpecentes (fls. 179/182, fls. 199/202 e fls. 183/186), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição aos réus, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

Vejamos:

Em solo policial, o acusado ADOLFO confessou parcialmente os fatos, afirmando que "estava com quinze bolinhas de "crack" em seu bolso esquerdo, pois é usuário de drogas, crack, cocaína e maconha; Que não estava em seu poder cocaína ou maconha e nem dinheiro pois já havia usado o dinheiro que tinha para comprar as pedras de "crack"; Que já esteve preso por seis meses e oito dias por tráfico de drogas no ano de 2018; Que no campo estava o interrogando e o rapaz que conhece como Kauã, o qual estava apenas fumando um baseado e também não estava com drogas.".

Em juízo, afirmou que quando eles viraram a viatura e já foram enquadrados. É um local de usuário. Estava com 15 porções de crack no bolso. Estava fumando as drogas. Depois disto foi levado para a guarda municipal e ali ficaram até onze horas da noite. Não estava com dinheiro. Tinha misturado maconha com crack, que chama "mesclado". Os objetos foram apreendidos, mas o que estava bolado eles jogaram no chão. Disse que ficou com eles o papel de seda e o isqueiro. Conhecia o Kauã de vista, jogam bola no mesmo campo de futebol. Cada um estava usando droga em um canto. Não tinha mais ninguém no local. Quem chegou primeiro foi o interrogado no local e depois de duas horas o corréu chegou. Disse que as outras drogas estavam dentro da viatura dele. Viu eles tirando de dentro da viatura. A blusa do interrogado não tem bolso. Na viatura também foi transportado o KAUÃ. O interrogado avisou o KAUÃ que os policiais estavam tirando droga de dentro da viatura. Quando chegaram na guarda que avisou o KAUÃ. O KAUÃ estava com umas pontas de maconha. Não conhecia o Alex e o Clovis. Não sabe porque eles iam querer mentir e forjar drogas, mas eles ficam querendo prejudicar os meninos. Não estava usando azul

Em solo policial, o acusado KAUÃ confessou parcialmente os fatos, afirmando "Que não tem advogado; Que só usa "maconha"; Que estava no campo de futebol com os moleques e estava fumando um baseado de "maconha" quando chegaram os policiais; Que todo mundo saiu correndo tendo o interrogando corrido também, sendo preso pelos policiais; Que trazia consigo umas pontas de baseado que guardava para levar para fumar em seu serviço; Que não estava realizando tráfico de drogas no local; Que conhece Adolfo Henrique da Vila Mariazinha, pois também reside no local.".

Em juízo, disse que foi ao local buscar maconha para fumar e nisto aconteceu. Os policiais correram atrás do interrogado. Os policiais colocaram as drogas em Itapeva. O ADOLFO é prova disto. Tinham apenas bitucas de maconha. Não estava na posse da maconha. Tinham mais de oito meninos no local. O ADOLFO é conhecido e se conhecem desde meninos. Chegou depois para buscar a maconha, mas nisto ficou no local fumando. O ADOLFO não estava usando droga. Comprou neste lugar a droga. Neste lugar vende e usa droga. Disse que correram juntos e lá embaixo eles pegaram os réus. Nisso os meninos correram para o mato. Pegaram o interrogado, levaram na guarda municipal e de lá levaram em Itapeva. Não acharam nada com o interrogado. Viu que estava sendo forjado em Itapeva, dentro da viatura. Eles colocaram as sacolas em cima da viatura. Não lembra se foi encontrado com ele alguma coisa. Não viu nada sendo encontrado com o ADOLFO. Não conhecia o Clovis e o Alex, e não sabe porque eles mentiriam; acredita que porque os meninos correram. Estava no local juntos, tinha acabado de chegar quase.

As versões dos réus, todavia, se mostram incoerentes e isoladas nos autos.

A testemunha CLOVIS PEREIRA DA CRUZ, policial militar, ouvido em juízo, afirmou que no dia dos fatos estava de serviço com o parceiro Azevedo e em patrulhamento fizeram contato com um solicitante, indicando que no campo haviam cinco indivíduos na prática do crime de tráfico de drogas. Em virtude da denúncia foram ao local e ao entrarem na rua Ciro de Albuquerque avistaram cinco indivíduos neste campo onde o solicitante havia informado. Quando eles viram se esconderam em um matagal. Foram atrás deles e conseguiram prender o ADOLFO e KAUÃO. O KAUÃ estava com 16 "parangas" de maconha e com o ADOLFO ele segurava uma sacola com 88 pedras de "crack" e 81 pinos de cocaína e 45 reais em espécie. Então eles foram conduzidos à delegacia. Os réus alegaram que eram usuários. Os outros indivíduos não conseguiu identificar. Eles estavam em um "campinho" improvisado para jogar futebol. Era período noturno.

O local não é conhecido como ponto de uso de drogas, só ponto de venda de drogas. O pessoal que está vendendo drogas não deixa que as pessoas usem drogas ali. A sacola estava dentro da blusa do ADOLFO. As drogas do KAUÃ estavam dentro do bolso. Não lembra do KAUÃ, e o ADOLFO já abordou ele em outras situação. Em outras abordagens com o ADOLFO não foi encontrado nada com ele. A denúncia anônima foi genérica, porque as pessoas que denunciam possuem medo.

A testemunha ALEX AZEVEDO DA SILVA, policial militar, apresentou a mesma narrativa em solo policial.

Verifica-se, portanto, que finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

As versões dos réus não se sustentam, seja por estarem isoladas nos autos, sem qualquer prova testemunhal a corroborar o que disseram, seja porque apresentam diversas divergências, a evidenciar que mentem na tentativa de furtarem à responsabilidade penal.

Veja-se: enquanto ADOLFO alega que estava no local apenas ele e KAUÃ, que estavam separados no local quando a viatura policial chegou e que também estava fazendo uso de drogas, o acusado KAUÃ afirma que estavam na companhia de outros meninos, que estavam juntos no local quando os policiais chegaram e que não viu ADOLFO fazendo uso de drogas. Se não fosse apenas isto, quando tentar imputar que os policiais forjaram para incriminá-los, ADOLFO alega que visualizou as drogas dentro da viatura quando estava na Guarda Municipal, enquanto KAUÃ afirma que estavam já na Delegacia de Itapeva.

Enfim, as narrativas dos acusados são absolutamente contraditórias e não convencem. Por outro lado, os policiais militares narraram com segurança, clareza e harmonia que receberam denúncia anônima dando conta do tráfico no local, para lá se dirigiram e abordaram os réus na posse das drogas.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido e porque não o conheciam anteriormente –, são mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL.

CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Noutra perspectiva, além do firme relato dos policiais, a quantidade de drogas, o local em que realizada a apreensão, o dinheiro encontrado, à luz do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, autoriza concluir, com grau de certeza, que a droga destinava-se realmente à mercancia. A propósito, destaca-se que o próprio acusado

KAUÃ confirma que o local também se destina à venda de drogas, e as drogas apreendidas – 16 porções de maconha (foto de fl. 20) – não deixa dúvida de que destinavam à venda, seja porque o acusado não alega que lhe pertenciam, seja porque a grande quantidade e a forma de embalagem, sem qualquer apetrecho de uso, evidenciam que não eram para uso exclusivo.

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Nesse ponto, sobreleva mencionar que o delito de tráfico de drogas está descrito em tipo penal misto alternativo, de modo que, à caracterização do crime, basta a prática de apenas uma das ações típicas. O efeito prático disso é que, para que se configure o tráfico, não é imprescindível que o réu seja flagrado vendendo a mercadoria proibida, bastando a concretização de qualquer uma das dezoito condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre eles "guardar", com o intuito de venda.

Assim, considera-se demonstrada a intenção (dolo) dos réus de destinar 185 porções de drogas variadas ao consumo de terceiros, seja KAUÃ em relação a 16 (dezesseis) porções de maconha, pesando 19,1g de massa líquida; e ADOLFO em relação a 88 (oitenta e oito) porções de crack, pesando 16,8 de massa líquida; e 81 (oitenta e uma) porções de cocaína, pesando 13,1 de massa líquida, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas e não o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06.

Com isto, ainda que os réus sejam usuário de drogas – o que, saliento, não foi suficientemente comprovado –, tal circunstância não o isenta da prática criminosa. Nesse sentido:

"Apelação – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) – Não acolhimento (...) Circunstâncias da prisão reforçam o "animus" de traficância, pois o local da diligência é conhecido como ponto de tráfico e o apelante tentou empreender fuga após receber a voz de prisão – Bastante comum a figura do "traficante-usuário" ou "usuário-traficante", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício – De rigor a condenação por tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei 11.343/06) – Penas bem dosadas e regime inicial fixado corretamente, em atenção aos parâmetros legais aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo – Pedido de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Reincidência do sentenciado e gravidade concreta do delito (dada a natureza diversificada e a grande quantidade de drogas) evidenciam o risco de reiteração delitiva ("periculum libertatis") e tornam a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública (art. 312, "caput", CPP) – Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500269-39.2019.8.26.0344; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021)

Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Impõe-se, portanto, a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao concurso de pessoas (artigo 29, do Código Penal), não há como se reconhecer que os acusados estavam juntos na prática de tráfico no local, ou seja, que um estaria concorrendo para a venda das drogas do outro, porque nada foi demonstrado durante a instrução neste sentido e cada acusado estava na posse de entorpecentes de natureza distintas, assim, cada qual deverá responder pela posse

das drogas que possuíam quando da prisão em flagrante.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

(i) ADOLFO HENRIQUE MARTINEZ

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. Ademais, relembro que ações penais e inquéritos penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes (Súmula nº 444, do STJ). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram normais. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações. i) Natureza e quantidade da substância: a droga encontrada com o acusado (crack) é extremamente nociva à saúde pública, bem como detém alto poder destrutivo, causando considerável grau de dependência, além disto, a quantidade foi expressiva (porções de crack e 81 porções de cocaína), o que justifica a exasperação da pena nesta fase (HC 413.928/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 11/10/2017).

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena nesta fase em 1/6 (um sexto), tornando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência específica, conforme processo n. 0000089-60.2018.8.26.0691 (data do fato 02/12/2017 e trânsito em julgado para a defesa pela extinção da pena 19/08/2021). Conforme a jurisprudência, o legislador não estabeleceu os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados, entendendo-se que a fração mínima de 1/6 deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, mas quando há situações específicas, como é o caso, reincidência específica, é permitido o aumento superior a 1/6. Neste sentido: Apelação Criminal 0000011-85.2014.8.26.0536. Assim, exaspero a pena nesta fase em 1/5 (um quinto) e fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, estabeleço a pena final do réu em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

(ii) KAUÃ DE LIMA LOPES

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. Ademais, relembro que ações penais e inquéritos penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes (Súmula nº 444, do STJ). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram normais. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado, uma vez que

na data dos fatos constava com apenas 19 (dezenove) anos, contudo, a pena já se encontra em seu patamar mínimo, motivo pelo qual não comporta maior redução da pena conforme Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento de pena. Entendo que o acusado faz jus ao redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, considerando que é primário, não ostenta maus antecedentes, e não há prova de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Ademais, considerando que a quantidade não foi expressiva (16 porções de maconha), aliada às demais circunstâncias favoráveis entendo que faz jus à fração máxima da diminuição, em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Assim, estabeleço a pena final do réu em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

(i) ADOLFO HENRIQUE MARTINEZ

Diante da reincidência específica do acusado, do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e da existência de circunstâncias judiciais negativas, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o quantum da pena e reincidência específica.

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

(ii) KAUÃ DE LIMA LOPES

Considerando: (i) a primariedade do acusado, (ii) o quantum de pena privativa de liberdade aplicada, (iii) a ausência da hediondez do crime (tráfico privilegiado), (iv) a inexistência de outros elementos a indicar uma gravidade em concreto do delito para justificar a fixação de regime mais gravoso, (v) a presença das atenuantes da menoridade relativa e confissão, entendo que se mostra suficiente e adequada a fixação do regime inicial aberto (artigo 33, parágrafo 2º, alínea c' do Código Penal).

A lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019, aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, "§ 5º não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas prevista no § 4º, do artigo 33 da lei 11.343/06", assim tornado cabível a fixação de regime menos gravoso, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente.

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do pagamento à entidade pública ou privada com destinação social, a ser especificada no momento da execução; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, consistente na atribuição de tarefas gratuitas a ser especificada no momento da execução da pena e de acordo com as aptidões da condenada, devendo ser cumprida à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em período que não prejudique a jornada normal de trabalho.

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (art. 77, inciso III, do Código Penal).

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Não há bens apreendidos nos autos para serem destruídos.

Determino a imediata destruição das drogas caso ainda não tenha sido realizada, e declaro a perda do valor apreendido em favor da União.

Em relação ao réu ADOLFO, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções. A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido: "Apelação – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria bem demonstradas – Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Ré confessa, ademais – Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos – Precedentes – Pena de multa que se corrige – Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante – Regime fechado justificado – Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito – Detração – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais – Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei).

VII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para:

(i) CONDENAR ADOLFO HENRIQUE MARTINEZ à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa no mínimo legal, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,

(ii) CONDENAR KAUÃ DE LIMA LOPES à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo a pena privativa de liberdade SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do pagamento à entidade pública ou privada com destinação social, a ser especificada no momento da execução; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, consistente na atribuição de tarefas gratuitas a ser especificada no momento da execução da pena e de acordo com as aptidões da condenada, devendo ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, em período que não prejudique a jornada normal de trabalho.

Mantenho a prisão preventiva do réu ADOLFO, à luz da condenação que ora se impõe, bem como do fato de ter permanecido presa durante o curso do processo. Além disso, não se verifica qualquer alteração no cenário levado em consideração no momento da decretação da prisão preventiva (fls. 70/72), de modo que persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Saliento que o acusado é reincidente específico pelo tráfico, estava na posse de expressiva quantidade de drogas, de caráter extremamente nocivo (crack), a evidenciar que sua soltura coloca em risco à ordem pública. Assim, não permito que recorra em liberdade.

Por outro lado, permito que o réu KAUÃ recorra em liberdade, considerando que respondeu a todo o processo solto, inexistindo os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do Código de Processo Penal, observados os benefícios da justiça gratuita.

Arbitro honorários no máximo da tabela aos advogados dativos nomeados para defesa dos interesses do réu.

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Lancem o nome do réu no rol dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. 4) Oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se o caso. 5) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, se o caso. 6) Expeçam-se certidões de honorários.

Oportunamente, arquivem-se os autos."

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário. Saem os presentes intimados.

Em seguida, após a leitura dos principais termos da sentença para as partes e oportunizada a consulta de forma escrita, as partes foram questionadas e:

Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença proferida. Pela Defesa e pelo réu Adolfo foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença proferida.

Pela Defesa e pelo réu Kauã foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença proferida.

Por fim, pela MM. Juíza foi dito:

"1. Dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para a ACUSAÇÃO, para a DEFESA técnica e para ambos os réus.

2. A PRESENTE SENTENÇA VALERÁ COMO TERMO DE ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO À(S) PENA(S) RESTRITIVA(S) DE DIREITO ACIMA IMPOSTA(S) AO ACUSADO KAUÃ, SENDO O SENTENCIADO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO E ADVERTIDO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, dispensando-se a realização de nova audiência para o mesmo fim. O sentenciado Kauã sai intimado, nesta data, a comparecer junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para dar início ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade imposta, sendo que na hipótese de ausência injustificada poderá haver a revogação do benefício. Oficie-se à Secretaria de Desenvolvimento Social.

O sentenciado Kauã também sai intimado a efetuar o pagamento da prestação pecuniária fixada, ficando autorizado, desde já, o parcelamento em até 6 vezes (prestações mensais, iguais e sucessivas), sendo que na hipótese de ausência injustificada poderá haver a revogação do benefício.

O sentenciado Kauã sai intimado, ainda, a efetuar o pagamento do valor a que foi condenado a título de multa, ficando autorizado, desde já, o parcelamento em até 6 vezes (prestações mensais, iguais e sucessivas). O pagamento da multa penal será efetuado no BANCO DO BRASIL, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, CNPJ nº

96.291.141/0001-80, de titularidade da Secretaria da Administração Penitenciária - SAP, que administra o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUNPESP, juntando-se comprovante do depósito bancário nos autos (artigo 481, das NCGJ).

3. Expeça-se o necessário para cumprimento das penas dos acusados. Efetuadas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se."

Intime-se."

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do programa Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 1350/2020. O termo de audiência foi assinado eletronicamente pelo(a) juiz(a), nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, (PATRIK SUDARIO DE SOUZA PEREIRA), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA